Aktenzeichen:
7 O 43/16

Landgericht Mannheim

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

[ ]

gegen

[ ]

wegen Patentverletzung

hat das Landgericht Mannheim - 7. Zivilkammer - durch ... auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 30.09.2016 für Recht erkannt:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland

   Sekundärstationen zum Einsatz in einem Funkkommunikationssystem mit einem Übertragungskanal zur Übertragung von Datenpaketen von einer Primärstation zu der Sekundärstation, wobei Empfangsmittel vorgesehen sind, um ein Datenpaket von der Primärstation zu empfangen, und Rückmeldungsmittel vorgesehen sind, um der Primärstation ein Signal zur Angabe des Status eines empfangenen Datenpakets zu übermitteln, wobei das Signal aus einer Gruppe von mindestens zwei zur Verfügung

stehenden Signaltypen ausgewählt wird, wobei die Rückmeldungsmittel so eingerichtet sind, dass sie den Leistungspegel auswählen, bei dem das Signal in Abhängigkeit seines Typs sowie in Abhängigkeit einer Angabe des Leistungspegels gesendet wird, bei dem jeder Signaltyp übermittelt wird, wobei die Angabe von der Primärstation zu der Sekundärstation übertragen wird

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

2. der Klägerin in einer gesonderten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben zu 2.a und b unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie seit dem 9. Juni 2012 die zu I.1. bezeichneten Handlungen begangen hat und zwar unter Angabe

   a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

   b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

   c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

   d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen;

   e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

   wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten und seit dem 9. Juni 2012 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

4. Die Beklagte wird verurteilt,

   a) die vorstehend unter Ziffer I.1. bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen und endgültig zu entfernen

   b) die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu I.1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder oder zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben.

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

III. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung

- in Höhe von jeweils € 800.000 in Ziffer I.1., I.4a) und I.4.b),
- in Höhe von € 50.000 in Ziffer I.2
- und im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages (Ziffer III. Kosten).

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Frage einer Verletzung des Europäischen Patents EP 1 440 525 (im Folgenden: Klagepatent) durch die Beklagte, sowie über die aus der behaupteten Verletzung abgeleiteten Unterlassungs-, Auskunfts-/Rechnungslegungs-, Schadensersatz-, Rückruf-/ Entfernungs- sowie Vernichtungsansprüche.

Die Klägerin ist ein weltweit operierendes Elektronikunternehmen, das u.a. auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie zahlreiche Patente hält.

Die Beklagte vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland u.a. LTE-fähige Mobiltelefone unter der Marke „A". Sie steht seit dem 29.08.2016 im mittelbaren Alleinbesitz der B Ltd. (im Folgenden B), die von der chinesischen D Mobile Technology Corp. kontrolliert wird. Davor hielt die B mittelbar 51 % der Anteile an der Beklagten. Die B ist zugleich die Alleingesellschafterin der französischen A SAS, die die Webseite www.Amobile.com hostet, unter der der Internetauftritt der einzelnen A-Landesgesellschaften erreichbar ist. Auch die Webseite der Beklagten wird unter dieser Domain unter der genannten Adresse gehostet.

Sie vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland UMTS- und LTE-fähige Mobiltelefone unter der Marke „A", u.a. die Modelle 1, 2, 3, 4 und 5 (vgl. beispielhaft Anlage K3a und b; im Folgenden: angegriffene Ausführungsformen).

Das UMTS-Netz, in dem auch die LTE-fähigen und UMTS-fähigen Mobiltelefone der Beklagten arbeiten können, beruht u.a. auf folgenden verpflichtend einzuhaltenden Standards:

- ETSI TS 123 002 V5.12.0 (2003-09),
- ETSI TS 125 211 V5.8.0 (2005-12),
- ETSI TS 125 214 V5.9.0 (2004-06),
- ETSI TS 125 213 V5.6.0 (2005-06),
- ETSI TS 125 331 V5.24.0 (2009-07).

Die Beklagte hat Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent zum Bundespatentgericht erhoben (Anlagen(konvolut) AR 1).

Die Klägerin ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in Kraft stehenden Klagepatents betreffend ein Funkkommunikationssystem, das unter Inanspruchnahme einer britischen Priorität vom 19. Oktober 2001 am 15. Oktober 2002 angemeldet wurde. Die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung erfolgte am 9. Mai 2012.

Anspruch 10 lautet (in der deutschen Übersetzung mit Bezugsziffern):

> „Sekundärstation (110) zum Einsatz in einem Funkkommunikationssystem mit einem Übertragungskanal zur Übertragung von Datenpaketen von einer Primärstation (100) zu der Sekundärstation, wobei Empfangsmittel vorgesehen sind, um ein Datenpaket (202) von der Primärstation zu empfangen, und Rückmeldungsmittel vorgesehen sind, um der Primärstation ein Signal (204, 206) zur Angabe des Status eines empfangenen Datenpakets zu übermitteln, wobei das Signal aus einer Gruppe von mindestens zwei zur Verfügung stehenden Signaltypen ausgewählt wird, wobei die Rückmeldungsmittel so eingerichtet sind, dass sie den Leistungspegel auswählen, bei dem das Signal in Abhängigkeit seines Typs sowie in Abhängigkeit einer Angabe des Leistungspegels gesendet wird, bei dem jeder Signaltyp übermittelt wird, wobei die Angabe von der Primärstation zu der Sekundärstation übertragen wird."

Hinsicht des gesamten Inhalts der Klagepatentschrift wird auf die Klagepatentschrift verwiesen.

Die Klägerin wies die französische A SAS vor Klageerhebung schriftlich am 13. Oktober 2014 (Anlage K 4a) unter Beifügung einer Liste der betroffenen Patente darauf hin, dass sie durch den Vertrieb ihrer Mobiltelefone UMTS- und LTE-standardessentielle Patente der Klägerin verletze. Die Klägerin bot der A SAS in der Folgezeit mehrere Treffen an, die indes nicht zustande kamen. In einem Telefonat Ende 2014 informierte die A SAS die Klägerin, dass ein Treffen im Dezember 2014 nicht möglich sei. In einer E-Mail vom 12.01.2015 (Anlage K 4e) teilte die A SAS mit, dass von der Klägerin vorgeschlagene Termine für ein Treffen im Januar aufgrund des Aufenthalts ihrer Direktion im Ausland nicht wahrgenommen werden könnten. Auf weitere Terminsvorschläge der Klägerin für den Zeitraum Ende Februar bis Mitte März 2015 mit E-Mail vom 10.02.2015 (Anlage K 4f) reagierte die A SAS nicht. Mit Schreiben vom 28. Juli 2015 (Anlage K 4g) unterbreitete die Klägerin der A SAS ein Lizenzvertragsangebot (Anlage K 4g, Anhang 4) unter Beifügung einer Liste der patentverletzenden Produkte und standardessentiellen Patente (Anlage K 4g, Anhang 1 und 2) nebst technischen Beschreibungen (Anlage K 4g). Weitere technische Erläuterungen zu den UMTS- und LTE-

Patenten übersendete die Klägerin mit E-Mail vom 25. September 2015 (Anlage AR 11 mit Anhängen in Anlagen K 4h und K 4i). Es kam in der Folgezeit aber nicht zum Abschluss eines Lizenzvertrages zwischen den Parteien, weshalb die Klägerin durch Klageschrift vom 16. Oktober 2015, bei Gericht eingegangen am 19. Oktober 2015, Klage erhob. Mit Schreiben datierend ebenfalls vom 16. Oktober 2015 (AR 12), das am 20. Oktober 2015 an die Klägerin übersandt wurde, teilte die A SAS der Klägerin, dass sie stets willens sei, nach Treu und Glauben die Bedingungen einer Lizenz an werthaltigen Patente zu verhandeln. Am 19. Oktober 2015 war der A SAS eine französische Klageschrift der Klägerin betreffend nicht standard-essentielle Patente von deren französischen Prozessbevollmächtigten übermittelt worden. Die Beklagte, die vor der Klageerhebung von der Klägerin nicht direkt kontaktiert worden war, erklärte nach Klageerhebung ein Interesse an einer Lizenznahme und unterbreitete der Klägerin einen Lizenzvertrag, der als Lizenzgebiet Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie einen Lizenzsatz von x % (*Compliance Rate*) bzw. y % (*Standard Rate*) des Nettoverkaufspreises je Einheit vorsah, wobei die Benutzungshandlungen in der Vergangenheit mit einem reduzierten Lizenzsatz von z % vergütet werden sollten. Mit Schreiben vom 25. August 2016 bot die A SAS der Klägerin unter Vorlage eines Lizenzvertrags (Anlagen AR 18 und 19) mit Blick auf den anstehenden Erwerb der Alleingesellschafterstellung ihrer Eigentümerin an der Beklagten an, zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen, insbesondere zu den gleichen Lizenzsätzen, Lizenz am weltweiten LTE-/UMTS-Patentportfolio zu nehmen. Im selben Schreiben teilte die A SAS auch Umsatzzahlen mit (Anlage AR 20). Sie hinterlegte bei der Landesjustizkasse Bamberg Ende August 2016 einen Betrag von € ... (vgl. Hinterlegungsschein, Anlage AR 21), wobei dieser Betrag die Lizenzzahlungen für die weltweiten Verkäufe von LTE-/UMTS-fähigen Geräten im Zeitraum 2013 bis 31. Juli 2016 mit Ausnahme von Deutschland, der Schweiz und Österreich, kalkuliert auf der Grundlage des angebotenen Lizenzsatzes, in Höhe von EUR ... zzgl. eines Sicherheitszuschlags abdecken soll. Die Beklagte selbst hatte zuvor ebenfalls Auskunft zu ihren Verkaufszahlen erteilt und ihrerseits auf dieser Grundlage EUR ... hinterlegt.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten der Lizenzvertragsverhandlungen wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Die Klägerin trägt vor,

die nach dem UMTS-Standard arbeitenden angegriffenen Ausführungsformen machten von allen Merkmalen des Anspruchs 10 wortsinngemäßen Gebrauch, indem sie den nach UMTS vorgesehenen ARQ-(Automatic Repeat Request)-Prozess durchführen könnten.

Dies gelte insbesondere auch für das Merkmal f. Denn es sei insoweit ausreichend, dass im Standard der Leistungspegel als Leistungsversatz ΔACK/ΔNACK zu einem Bezugskanal definiert sei und von höheren Netzwerkebenen an die Mobilstation übertragen werde. Hingegen sei nicht erforderlich, dass der Leistungspegel als absolute Größe in dB vorgegeben werde. So hebe auch die Beschreibung in Abschnitten [0026], [0029] und [0048] auf einen Leistungsversatz ab. Unschädlich sei überdies, dass der Leistungsversatz ΔACK/ΔNACK nicht jedes Mal mit dem Informationselement „Uplink DPCH Power Control Info" übertragen werde, sondern nur dann, wenn sich eine Veränderung ergebe. Denn jedenfalls müsse der Leistungsversatz mindestens einmal übertragen werden, weil sonst eine notwendige Bedingung für eine Übertragung auf den Kanälen HS-SCCH und HS-DSCH nach den Vorgaben des Standards ETSI TS 125 331 V5.24.0 (2009-07), Abschnitt 10.3.6.91, Seite 546 in der dortigen Tabelle nicht erfüllt sei. Auch eine „Auswahl" sei durch die Notwendigkeit einer vorherigen Berechnung nicht in Frage gestellt.

Das Klagepatent werde sich als rechtsbeständig erweisen.

Schließlich greife der von der Beklagten erhobene kartellrechtliche Einwand nicht durch, da sie die A SAS insbesondere vor Klageerhebung in ausreichender Weise über die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr ihres FRAND-Angebots informiert und damit alle Obliegenheiten, die der Europäische Gerichtshof in der Entscheidung Huawei./.ZTE formuliert habe, bereits vor Klageerhebung erfüllt habe. Hierfür genüge die Mitteilung der verlangten Lizenzgebühr je Einheit und die Hinweise auf den Umfang und die territoriale Abdeckung des Patentportfolios sowie auf den technischen Beitrag der Klägerin zur Entwicklung des UMTS/LTE-Standards in den Schreiben vom 13. Oktober 2014 (Anlage K 4a), 28. Juli 2015 (Anlage K 4g) und 25. September 2015 (Anlagen K 4h und K 4i). Zu näheren Erläuterungen sei sie gegenüber der im Grundsatz lizenzunwilligen Beklagten ohnedies nicht verpflichtet gewesen.

Die Klägerin **b e a n t r a g t**:

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000 - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlungen bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an ihrem jeweiligen Geschäftsführer zu vollstrecken ist, zu unterlassen,

Sekundärstationen zum Einsatz in einem Funkkommunikationssystem mit einem Übertragungskanal zur Übertragung von Datenpaketen von einer Primärstation zu der Sekundärstation, wobei Empfangsmittel vorgesehen sind, um ein Datenpaket von der Primärstation zu empfangen, und Rückmeldungsmittel vorgesehen sind, um der Primärstation ein Signal zur Angabe des Status eines empfangenen Datenpakets zu übermitteln, wobei das Signal aus einer Gruppe von mindestens zwei zur Verfügung stehenden Signaltypen ausgewählt wird, wobei die Rückmeldungsmittel so eingerichtet sind, dass sie den Leistungspegel auswählen, bei dem das Signal in Abhängigkeit seines Typs sowie in Abhängigkeit einer Angabe des Leistungspegels gesendet wird, bei dem jeder Signaltyp übermittelt wird, wobei die Angabe von der Primärstation zu der Sekundärstation übertragen wird

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

- unabhängiger Anspruch 10 -

2. der Klagerin zu 1 in einer gesonderten Aufstellung, hinsichtlich der Angaben zu 2.a. und b. unter Vorlage von Rechnungen oder Lieferscheinen oder Quittungen, darüber Angaben zu machen, in welchem Umfang sie die zu I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 9. Juni 2012 begangen hat, und zwar unter Angabe

   a. der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse, sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

   b. der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen, den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

   c. der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen, der jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

   d. der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und den Schaltungszeiträumen,

   e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

   wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht-gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin zu 1 einem von ihr zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten vereidigten

Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I.1. bezeichneten und seit dem 9. Juni 2012 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte wird verurteilt,

1. die vorstehend unter Ziffer I.1 bezeichneten, im Besitz Dritter befindlichen und seit dem 9. Juni 2012 auf den Markt gebrachten Erzeugnisse aus den Vertriebswegen zurückzurufen, indem diejenigen Dritten, denen durch die Beklagte oder mit deren Zustimmung Besitz an den Erzeugnissen eingeräumt wurde, unter Hinweis darauf, dass die Kammer mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents DE 602 42 895.5 (deutscher Teil des EP 1 440 525) erkannt hat, ernsthaft aufgefordert werden, die Erzeugnisse an die Beklagte zurückzugeben und den Dritten für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Rückzahlung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises sowie die Übernahme der Kosten der Rückgabe zugesagt wird, und endgültig zu entfernen, indem die Beklagte diese Erzeugnisse wieder an sich nimmt oder die Vernichtung derselben beim jeweiligen Besitzer veranlasst,

2. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum befindlichen, vorstehend zu I.1. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben (alternativ an einen zur Vernichtung bereiten Gerichtsvollzieher).

Die Beklagte **b e a n t r a g t**,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise:

- den Rechtsstreit bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage vom 12. Mai 2016 auszusetzen, hilfsweise den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts auszusetzen,
- Abwendungsbefugnis.

Die Beklagte trägt vor,

das Klagepatent werde nicht verletzt, da es an einer Verwirklichung des Merkmals f fehle. Es werde nur ein Leistungsversatz und kein Leistungspegel übertragen. Zudem sei die Übertragung der Werte ΔACK/ΔNACK nur optional und finde nicht jedes Mal statt. Zudem sei nicht schlüssig dargelegt, dass eine Übertragung von der Primär- an die Sekundärstation erfolge, weil nach dem Standard auch eine Festlegung durch höhere Schichten des Mobiltelefons in Betracht komme. Ferner finde keine klagepatentgemäße Auswahl statt, sondern nur eine Berechnung. Die patentgemäße Auswahl erfordere indes eine unmittelbare Auswahl ohne das Dazwischentreten einer solchen Berechnung – der Leistungspegel müsse schon in der Primärstation vorhanden sein und an die Sekundärstation übermittelt werden.

Im Übrigen stehe der Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand entgegen. Die Klägerin habe insbesondere vor Klageerhebung nie erläutert, weshalb die von ihr geforderte Stücklizenz FRAND-Bedingungen entspreche. Die Lizenzbereitschaftserklärung der A SAS mit Schreiben vom 16.10.2015 sei nicht verspätet erfolgt, da der A SAS eine ausreichende Zeitspanne zur Prüfung der überlassenen Unterlagen zuzugestehen sei. Maßnahmen gegenüber der A SAS seien der Beklagten überdies ohnehin nicht zuzurechnen. Die Beklagte sei bis zur Veränderung ihres Gesellschafterbestands vor dem 29.08.2016 von keiner anderen A-Gesellschaft beherrscht worden, da verschiedene Geschäftsgegenstände, darunter auch der Abschluss eines Lizenzvertrags, nach ihrem Gesellschaftsvertrag Einstimmigkeit bedurft hätten.

Zudem werde sich das Klagepatent nicht gegenüber dem Nichtigkeitsangriff behaupten können.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Parteivortrags – auch bezüglich der im auf Antrag hinzugezogenen Akten des Verfahrens 7 O 212/15 vollständig vorgelegten Anlage K4g – wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und das Protokoll über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und weit überwiegend begründet. Lediglich soweit die Klägerin beantragt hat, der Beklagten für die Art und Weise des Rückrufs und der Entfernung verletzender Gegenstände aus den Vertriebswegen Vorgaben zu machen, war die Klage abzuweisen.

Da die angegriffenen Ausführungsformen von der Lehre des geltend gemachten Hauptanspruchs 10 unmittelbar wortsinngemäßen Gebrauch machen, war die Beklagte zur Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen sowie Vernichtung und Auskunft/Rechnungslegung zu verurteilen und ihre Schadensersatzverpflichtung festzustellen. Die Geltendmachung dieser Ansprüche unterliegt auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen Einschränkungen.

I.1. Das Klagepatent betrifft ein Funkkommunikationssystem, welches insbesondere bei UMTS-Verfahren (Universal Mobile Telecommunication System) zwischen einer Primärstation und einer Sekundärstation Anwendung findet.

Die Beschreibung verweist auf ein zunehmendes Bedürfnis danach, große Datenmengen im Wege der Mobilfunkkommunikation an eine Mobilstation zu übertragen wie etwa Internetseiten, die auch Videoclips enthalten. Zu diesem Zweck sei in UMTS das High Speed Downlink Packet Access-(HSDPA)-Verfahren entwickelt worden. Bekannter Bestandteil eines solchen Datenübertragungssystems sei ein Automatic Repeat Request-(ARQ)-Verfahren, das sich mit der fehlerhaften Übertragung von Daten befasse. Die Mobilstation bestimme im HSDPA-Verfahren, ob ein Datenpaket beschädigt worden sei, indem etwa CRC-Informationen genutzt würden. Danach würde von der Mobilstation bei korrektem Empfang eine ACK-Nachricht, bei beschädigtem Empfang eine NACK-Nachricht gesendet. Indes könnten sich auch bei der Übertragung der ACK- und NACK-Nachrichten Probleme ergeben, wenn diese durch den Empfänger fehlerhaft gedeutet würden. Besonders problematisch sei der Fall, dass eine NACK-Nachricht als ACK-Nachricht missverstanden werde, weil eine Korrektur dieses Fehlers nur unter großem Ressourcenaufwand vorgenommen werden könne. Um die Systemleistungsfähigkeit zu erhöhen, sei es daher wünschenswert, die Fehleranfälligkeit der ACK-/NACK-Decodierung zu kontrollieren. Dies könne in UMTS etwa bewerkstelligt werden, indem die Mobilstation das ACK-/NACK-Codewort mit einem bestimmten Leistungsniveau, das die Basisstation vorgebe, übertragen müsse. Das Leistungsniveau könne unter Abwägung verschiedener Umstände gewählt werden.

In der deutschen Patentanmeldung DE 10132566 werde das Problem hingegen durch die Übersendung eines zusätzlichen Codewortes REVERT gelöst. Aus der US-Schrift 4888767 sei wiederum bekannt, ein Wiederholungsanfragesignal zu übersenden, wenn ein Datenpaket beschädigt empfangen wurde. Die US-Schrift 5517507 übersende dagegen ACK/NACK-Nachrichten auf besondere Weise. So werde ein NACK-Signal durch einen Energieschub repräsentiert, ein ACK-Signal sei hingegen durch einen Ausbleiben eines solchen Energieschubs gekennzeichnet. Die Erfindung setze sich somit zum Ziel, ein effizienteres System für die Übertragung von Datenpaketen vorzustellen.

Diese Aufgabe soll erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung mit den nachfolgenden Merkmalen des Anspruchs 10 gelöst werden:

a) Sekundärstation (110) zum Einsatz in einem Funkkommunikationssystem
b) Das Funkkommunikationssystem verfügt über einen Übertragungskanal zur Übertragung von Datenpaketen von einer Primärstation (100) zu einer Sekundärstation.
c) Empfangsmittel sind vorgesehen, um ein Datenpaket (202) von der Primärstation zu empfangen.
d) Rückmeldungsmittel sind vorgesehen, um der Primärstation ein Signal (204, 206) zur Angabe des Status eines empfangenen Datenpakets zu übermitteln.
e) Das Signal wird aus einer Gruppe von mindestens zwei zur Verfügung stehenden Signaltypen ausgewählt.
f) Die Rückmeldungsmittel sind so eingerichtet, dass sie den Leistungspegel auswählen, bei dem das Signal
   f1) in Abhängigkeit seines Typs
   f2) sowie in Abhängigkeit einer Angabe des Leistungspegels gesendet wird, bei dem jeder Signaltyp übermittelt wird, wobei die Angabe von der Primärstation zu der Sekundärstation übertragen wird.

2. Die angegriffenen Ausführungsformen machen von Anspruch 10 des Klagepatents wortsinngemäßen Gebrauch.

a) Dies steht zwischen den Parteien bis auf das Merkmal f außer Streit und beruht auch nicht auf patentrechtlich unzutreffenden Anschauungen.

b) Wie der Durchschnittsfachmann die Kombination der Merkmale versteht, ergibt sich ausgehend vom Patentanspruch (§ 14 S. 1 PatG) aus dem technischen

Zusammenhang seiner Merkmale, sowie aus dem Inhalt der Beschreibung und Zeichnungen (§ 14 S. 2 PatG). Durch Heranziehung der Beschreibung zur Auslegung der Patentansprüche wird sichergestellt, dass der tatsächliche Sprachgebrauch des Patents hinreichende Beachtung findet. Der Fachmann orientiert sich also an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekommenen Zweck eines Merkmals, womit der technische Sinn der in der Patentschrift benutzten Worte und Begriffe - nicht die philologische oder logisch-wissenschaftliche Begriffsbestimmung - entscheidend ist, die Patentschrift gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellt (BGHZ 150, 149, 156 - Schneidmesser I; BGH, Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Dabei schränken die Ausführungsbeispiele sowie die darauf bezogenen Beschreibungsteile einen weiter zu verstehenden Sinngehalt der Patentansprüche nicht auf diese Ausführungsformen ein. Eine Auslegung unterhalb des Wortlauts (im Sinne einer Auslegung unterhalb des Sinngehalts) der Patentansprüche ist generell nicht zulässig.

c) Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen auch Merkmal f.

aa) Zur Verwirklichung des Merkmals ist es ausreichend, dass der Leistungspegel, mit dem eine ACK- oder eine NACK-Nachricht von der Primärstation erwartet wird, als Leistungsversatz zu einem Bezugskanal und dessen Übertragungspegel bestimmt werden kann. Denn technisch-funktional ist es ohne Belang, ob die Primärstation die ACK-/NACK-Nachricht deshalb zutreffend als ACK- oder NACK-Nachricht erkennt, weil ihr der Leistungspegel in dB als absolute Größe bekannt ist oder ob sie in einem Zwischenschritt diese Größe durch Berechnung erst bestimmt, in dem sie den konkreten Leistungspegel über eine Differenzbildung zum Leistungspegel eines Bezugskanals errechnet. In beiden Fällen ist das technische Ziel erreicht, dass die Primärstation weiß, welches Leistungsniveau in der konkreten Situation eine ACK-Nachricht aufweist und welches Leistungsniveau eine NACK-Nachricht kennzeichnet, sodass eine korrekte Interpretation sichergestellt wird. Aus diesem Grund vollzieht sich beim Standard auch eine Auswahl eines Leistungspegels, weil auch insoweit das Dazwischentreten einer Berechnung eine patentgemäße Auswahl des Leistungspegels entsprechend der netzseitigen Vorgabe nicht hindert. Dies folgt auch aus der eigenen Argumentation der Beklagten, die die Übermittlung eines absoluten Leistungspegels für die ACK-Signale und eines Leistungsversatzes ACK/NACK-Offset für die NACK-Signale für patentgemäß

erachtet, wobei dann die Ermittlung des Leistungspegels der NACK-Signale sich auch erst durch eine Berechnung ableiten lässt.

bb) Der Wortlaut des Anspruchs schließt bei patentrechtlich zutreffender Würdigung auch nicht aus, dass das funktionale Ziel über die Bestimmung eines Leistungsversatzes erreicht wird. Dabei ist auch nicht allein ein solcher Leistungsversatz als patentgemäß anzusehen, der sich aus einer Angabe des Versatzes gegenüber einer absoluten Angabe eines Leistungswertes für das ACK-Signal ergibt, wie die Beklagte meint. Denn das Merkmal f2 verlangt lediglich, dass die Rückmeldungsmittel den Leistungspegel, mit dem sie die ACK-/NACK-Nachrichten übersenden „in Abhängigkeit einer Angabe des Leistungspegels" wählen. Damit ist allein erforderlich, dass die ACK-/NACK-Nachrichten gleichsam durch einen bestimmten für den Typ individuellen Bezug zum Leistungspegel gekennzeichnet und erkennbar sind, ohne dass nach dem Wortlaut zu fordern wäre, dass die Primärstation einen absolut bestimmten Leistungspegel vorgeben müsste und eine Bestimmung desselben durch eine Relation zu einer bekannten Bezugsgröße wie dem Leistungspegel eines anderen Kanals ausgeschlossen wäre.

cc) Für eine solche Auslegung des Wortlauts streiten auch die in den Abschnitten [0026], [0029] und [0048] der Beschreibung vorgestellten Ausführungsbeispiele, auf die die Klägerin Bezug nimmt und die auf die Übertragung eines „ACK/NACK power offsets" und damit eines Leistungsversatzes abheben. Selbst wenn insoweit nur ein Leistungsversatz der NACK-Signalisierung gegenüber einem ggf. absolut angegebenen ACK-Leistungspegel abgehoben werden sollte, lässt sich aus diesem bloßen Ausführungsbeispiel nicht der Rückschluss ableiten, dass eine Berechnung des Leistungspegels von ACK/NACK über einen Versatz zu einer anderen feststehenden Bezugsgröße wie etwa der Leistung eines anderen Kanals nicht zur Lehre des Klagepatents zählen soll. Diese Ausführungsbeispiele lesen sich im Zusammenhang mit dem erteilten Anspruch 10 nicht im Sinne einer bewussten Auswahlentscheidung des Anmelders gegen die Erteilung von Patentschutz auch für diese Ausführungsbeispiele im Sinne der Entscheidung Okklusionsvorrichtung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 189, 330) wie die Beklagte meint. Denn die Patentschrift ist in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den

Zeichnungen ergeben (BGHZ 189, 330 Rn. 24 - Okklusionsvorrichtung). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGHZ 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung). Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können (BGH, Urteil vom 2. Juni 2015, X ZR 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 23 – Kreuzgestänge).

Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe lässt sich die Verwendung eines Leistungsversatzes zu einem Bezugskanal, der eine Bestimmung des Leistungspegels der erwarteten ACK-/NACK-Nachrichten erlaubt, wie ausgeführt ohne weiteres unter den Wortlaut des Merkmals f2 lesen.

dd) Soweit die Beklagte argumentiert, der Standard sei insoweit nur optional, ist dies patentrechtlich ohne Belang, da der Anspruch nur fordert, dass die geschützten Vorrichtungen Mittel aufweisen, die geeignet sind, entsprechend dem Merkmalen f2 zu operieren. Dass die Parameter ΔACK-/NACK indes als Bestandteil des Informationselements „Uplink DPCH Power Control Info" mindestens einmal zur Mobilstation übertragen werden müssen, damit überhaupt ein Empfang von Datenpaketen über den HS-SCCH und den HS-DSCH im Rahmen des HSDPA-Verfahrens möglich ist, ergibt sich nach Überzeugung der Kammer aus dem von der Klägerin zitierten Standarddokument Abschnitt 8.5.25, Seite 251

8.5.25 Actions related to HS_DSCH_RECEPTION variable

The variable HS_DSCH_RECEPTION shall be set to "TRUE" only when all the following conditions are met:

1> the UE is in CELL_DCH state;

1> the variable H_RNTI is set;

1> the UE has a stored IE "HS-SCCH info";

1> the UE has a stored IE "MAC-hs info";

1> for FDD:

2> one of the radio links in the active set is configured as the serving HS-DSCH radio link;

2> the UE has stored the following IEs:

- IE "Measurement Feedback Info";
- IE "Uplink DPCH Power Control Info" including stored Δ_{ACK}, Δ_{NACK} and Ack-NACK Repetition factor.

Whenever the variable HS_DSCH_RECEPTION is set to FALSE, the UE shall:

1> not perform HS_SCCH reception procedures;

1> not perform HS-DSCH reception procedures.

sowie sich zudem aus Abschnitt 8.6.6.11, Seite 293

8.6.6.11 Uplink DPCH power control info

The UE shall:

1> in FDD:

2> if the IE "Uplink DPCH power control info" is included:

3> if a synchronisation procedure A is performed according to [29]:

4> calculate and set an initial uplink transmission power;

4> start inner loop power control as specified in subclause 8.5.3;

4> for the UL inner loop power control:

5> use the parameters specified in the IE.

3> else:

4> ignore the IEs "DPCCH Power offset", "PC Preamble" and "SRB delay";

4> act on the IE "Power control algorithm" and the IE "TPC step size", if included.

3> act on the IEs "Δ_{ACK}", "Δ_{NACK}" and "Ack-Nack repetition factor", if included.

ergibt, dass die übertragenen Parameter bei Übertragung auch verwendet werden.

ee) Dass sich die oben eingeblendete Passage nur auf den Frequenzduplexbetrieb (FDD) bezieht, ist unschädlich, weil dies die Funktionalität der angegriffenen Ausführungsformen, für diesen Fall wie beschrieben zu verfahren, nicht in Abrede stellt. Jedenfalls kann die standardgemäß ausgebildete angegriffene Ausführungsform entsprechend verfahren, wenn das Informationselement übertragen wird.

ff) Soweit die Parameter in der Tabelle in Abschnitt 10.3.6.91 auf Seite 546 des Standards als optional gekennzeichnet sind,

Information Element/Group name	Need	Multi	Type and reference	Semantics description	Version
CHOICE mode	MP				
=FDD					
==DPCCH Power offset	MP		Integer(-10,4...-6 by step of 2)	In dB	
==PC Preamble	MP		Integer (0..7)	In number of frames	
==SRB delay	MP		Integer(0..7)	In number of frames	
==Power Control Algorithm	MP		Enumerated (algorithm 1, algorithm 2)	Specifies algorithm to be used by UE to interpret TPC commands.	
==TPC step size	CV-algo		Integer (1..2)	In dB	
==Δ_{PRACH}	OP		Integer (0..8)	Refer to quantization of the power offset in [26]	REL-5
==Δ_{PCH}	OP		Integer (0..8)	refer to quantization of the power offset in [26]	REL-5
==Ack-Nack repetition factor	OP		Integer(1..4)		REL-5

hat die Klägerin dies zutreffend lediglich als insoweit optional beschrieben, als dass die Parameter nicht bei jeder Übersendung des Informationselements „Uplink DPCH Power Control Info" erneut übersendet werden müssen, soweit es hierfür kein technisches Bedürfnis gibt. Dies stellt damit nicht in Abrede, dass für jedes übertragene Datenpaket eine Rückmeldung bezüglich des korrekten oder inkorrekten Empfanges gegeben wird, sondern es wird lediglich bei entsprechendem Bedarf der Leistungspegel über die Mitteilung des Leistungsversatzes verändert, den die von der Primärstation erwarteten ACK-/NACK-Nachrichten aufweisen sollen.

gg) Dass wiederum das Informationselement „Uplink DPCH Power Control Info" vom UTRAN, d.h. netzwerkseitig, an das User Equipment, also die Mobilstation, übertragen wird, folgt aus dem gerichtsbekannten Standarddokument ETSI TS 125.331, dort Abschnitt 10.2.16a, der als Übertragungsrichtung „UTRAN → UE" angibt und das Element „Uplink DPCH Info" unter Downlink radio ressources aufführt. Auch soweit die Standardstelle sich nur auf den speziellen Fall eines Handovers zum Netz UTRAN etwa vom GSM-Netz beziehen mag, so wird hierdurch aus Sicht der Kammer nicht in Abrede gestellt, dass sich die Signalisierung von der Primär- an die Sekundärstation vollzieht. Denn selbst wenn hier in die Kommunikation die Primärstation eines anderen Netzes zwischengeschaltet ist, ändert dies nichts an der Tatsache, dass die Vorgabe insoweit netzwerkseitig erfolgt.

hh) Entsprechend ändert auch der Umstand, dass das Informationselement „Uplink DPCH info" nicht immer den Bestandteil „Uplink DPCH power control info" enthält,

nichts an der Eignung der angegriffenen Ausführungsformen, im Falle der Übersendung nach dem Standard entsprechend zu verfahren.

II. Die festgestellten patentverletzenden Handlungen rechtfertigen die zu dem Klagepatent gestellten Anträge.

1. Der Unterlassungsanspruch ergibt sich aus Art. 2 Abs. 2, 64 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG. Die Lieferung und das Anbieten der angegriffenen Ausführungsformen in der Vergangenheit rechtfertigt die Verurteilung zur Unterlassung, da eine Wiederholungsgefahr gegeben ist.

2. Die Beklagte ist der Klägerin aufgrund der vorliegenden Verletzung des Klagepatentes zur Auskunft und Rechnungslegung verpflichtet. Die Klägerin kann den Schadensersatzanspruch nicht ohne Kenntnis der Umstände, über die sie Auskunft fordert, berechnen. Da diese Umstände der Klägerin als Betriebsinterna der Beklagten naturgemäß unbekannt sind, die Beklagte hierüber aber anhand ihrer Buchhaltung ohne unzumutbaren Arbeitsaufwand Auskunft geben kann, ist die Beklagte gem. § 140 b PatG und einer zu Gewohnheitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB zur Auskunft verpflichtet. Diese Auskunft hat sich für die Zeit seit Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents zzgl. Kenntnisnahmefrist von einem Monat auch auf den Gewinn der Beklagten und die zu seiner Berechnung erforderlichen Daten zu beziehen. Die Klägerin muss durch die Auskunft erst in die Lage versetzt werden, sich für eine der möglichen Berechnungsarten ihres Schadensersatzanspruchs (Verletzergewinn, entgangener Gewinn oder fiktive Lizenz) zu entscheiden.

3. Zudem war wie beantragt festzustellen, dass die Beklagte in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zum Schadensersatz verpflichtet ist.

   a) Die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO liegen vor. Die Klägerin kennt den genauen Umfang der Benutzungs- und Verletzungshandlungen nicht. Ohne diese Kenntnis kann sie den Antrag auf Zahlung von Schadensersatz und Entschädigung nicht beziffern. Da aber die Beklagte Schadensersatzansprüche der Klägerin in Abrede stellt, hat die Klägerin – auch zur Hemmung der Verjährung und Herbeiführung der 30jährigen Verjährungsfrist – ein rechtliches Interesse daran, dass das Bestehen eines Schadensersatzanspruchs alsbald festgestellt wird.

b) Der Anspruch auf Schadensersatz ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Die Beklagte hat schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig gehandelt. Bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte sie spätestens einen Monat nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Erteilung des Klagepatents erkennen können und erkennen müssen, dass das Klagepatent durch die angegriffenen Ausführungsformen verletzt wird.

4. Die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf finden ihre Grundlage in Art. 2 Abs. 2, 64 EPÜ i.V.m. §§ 140a Abs. 3 Satz 1 PatG. Allerdings waren der Beklagten hinsichtlich der Art und Weise des Rückrufs und der Entfernung keine inhaltlichen Vorgaben zu machen, weshalb die Klage insoweit abzuweisen war.

III. Der gerichtlichen Durchsetzung der Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsansprüche stehen in Anwendung der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache Huawei./. ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817) kartellrechtliche Gründe nicht entgegen.

1. Die Kammer hat ihr Verständnis des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Sache Huawei Technologies/ZTE im Urteil vom 29. Januar 2016 - 7 O 66/15 (veröffentlicht bei juris) dargelegt und hält nach nochmaliger Überprüfung der dort vertretenen Rechtsauffassung an dieser Begründung fest. Aus Sicht der Kammer betont der Gerichtshof, dass das aus einem Patent fließende Ausschließlichkeitsrecht nur unter ganz besonderen Umständen nicht mit der Verletzungsklage durchsetzbar ist. Daraus folgt, dass die entsprechenden tatsächlichen Umstände, aus denen sich die Suspendierung des Patentrechts ergeben soll, von dem in Anspruch genommenen (angeblichen) Verletzer vorzutragen und wenn die Umstände im Streit stehen, auch zu beweisen sind.

   Der Gerichtshof entwickelt aus Sicht der Kammer in seinem Urteil ein Konzept, dass es dem zur Entscheidung berufenen Gericht ermöglichen soll, das Verhalten des Inhabers des SEP auf der einen Seite sowie des angeblichen Verletzers auf der anderen Seite daraufhin zu bewerten, ob sich die Durchsetzung der auf das SEP gestützten Unterlassungs- und Rückrufanträge als ungerechtfertigter Marktmissbrauch und Aufbau eines insoweit zu unterbindenden Drucks in der Verhandlungssituation zu bewerten ist

oder als gerechtfertigte Reaktion auf eine vom (angeblichen) Verletzer verfolgte Verzögerungstaktik. Hingegen zielt die Entscheidung des Gerichtshofs nach der Überzeugung der Kammer nicht darauf ab, die Verletzungsgerichte mit der Bestimmung der FRAND-Bedingungen zu belasten, wenn im Verfahren der Unterlassungs- und Rückrufanspruch durchgesetzt werden soll und es nicht gerade um die Zahlung einer FRAND-Lizenzgebühr im Betragsverfahren geht.

Zu diesem Zweck hält es der Gerichtshof für erforderlich, dass der Patentinhaber in einem ersten Schritt vor der Erhebung einer auf Rückruf und Unterlassung gerichteten Klage, die für den angeblichen Verletzer einen erheblichen Verhandlungsdruck aufbaut, einen angeblichen Verletzer auf die ihm vorgeworfene Patentverletzung hinweist und dabei das SEP bezeichnet sowie angibt, auf welche Weise es verletzt sein soll. Jedenfalls wird der Patentinhaber das mit der Klage geltend gemachte und von ihm standardessentiell deklarierte Patent mit seiner Patentnummer bezeichnen und angeben müssen, dass dieses Patent bei der betreffenden Standardisierungsorganisation als standardessentiell deklariert wurde. Soweit der Patentinhaber zudem angeben soll, auf welche Weise das Patent verletzt sein soll, muss der Hinweis dem Verletzer deutlich machen, für welchen Standard das Patent essentiell ist und aufgrund welcher Umstände der Patentinhaber davon ausgeht, dass der angebliche Patentverletzer von der Lehre des Patents Gebrauch macht. Jedenfalls ist dafür erforderlich, dass der Patentinhaber benennt, welche technische Funktionalität der angegriffenen Ausführungsform vom Standard Gebrauch macht. Der angebliche Verletzer wird regelmäßig nämlich im Bilde darüber sein, dass sein Produkt einem Standard gemäß ausgebildet ist. Daher dürfte ein bloßer Hinweis, der angebliche Verletzer stelle nach dem Standard arbeitende Produkte her oder vertreibe diese und verletze deshalb das Patent, nicht ausreichend sein. Vielmehr muss der angebliche Verletzer durch den Hinweis in die Situation versetzt werden, die Schutzrechtslage selbständig prüfen (lassen) zu können. Aufgrund der Vielzahl der technischen Funktionalitäten, die regelmäßig in einem Standard enthalten sind und die gerade die vom Gerichtshof angesprochene Unübersichtlichkeit bei der Beurteilung der Schutzrechtslage begründet, wird es erforderlich sein, dass der SEP-Inhaber jedenfalls die Kategorie der technischen Funktionalität des Standards in einer solchen Weise benennt, dass der vermeintliche Verletzer nun wieder der grundsätzlich ihm obliegenden Pflicht, die Schutzrechtslage zur prüfen, gerecht werden kann. Wie detailliert dieser Hinweis zu erfolgen hat, kann nur nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls entschieden werden. Hierbei wird insbesondere einzustellen sein, welche Technologiekenntnisse beim Patentverletzer vorhanden sind bzw.

inwieweit er sich solche Kenntnisse in zumutbarer Weise durch professionellen Rat zu verschaffen hat. Aus Sicht der Kammer sind zur Darlegung des Verletzungssachverhalts in einer den Anforderungen des Gerichtshofs entsprechenden Weise grundsätzlich jedenfalls – ohne hierauf beschränkt zu sein – die auch im Rahmen von Lizenzvertragsverhandlungen nach den geschäftlichen Gepflogenheiten sonst üblichen Claim-Charts ausreichend, die den geltend gemachten oder einen ihm verwandten Anspruch des Klagepatents, der gleichfalls die entscheidenden Merkmale aufweist, gegliedert nach Anspruchsmerkmalen den entsprechenden Stellen im Standard gegenüberstellen, ohne dass hierbei die Anforderungen der Schlüssigkeitsprüfung einer Verletzungsklage erfüllt werden müssen. Insoweit ist in der Regel ausreichend, dass der angebliche Verletzer den vom SEP-Inhaber erhobenen Vorwurf jedenfalls bei Hinzuziehung externen oder internen technischen Sachverstandes nachvollziehen kann.

Entsprechendes gilt für die weitere Obliegenheit des SEP-Inhabers, der zudem vor Klageerhebung dem angeblichen Patentverletzer – sofern dieser im Grundsatz seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, überhaupt Lizenz nehmen zu wollen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr und die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben hat. Vor dem Hintergrund des zuvor geschilderten Verständnisses, das die Kammer zu der Entscheidung des Gerichtshofs entwickelt hat, ist hierfür erforderlich, dass es sich um ein annahmefähiges Vertragsangebot handelt, das die vertragswesentlichen Bedingungen enthält. Soweit der Gerichtshof ausführt, dass der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenz-Angebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten hat, bedeutet dies nicht, dass das Verletzungsgericht für den Fall, dass der (angebliche) Patentverletzer – wie regelmäßig – in Abrede stellt, dass dieses Angebot FRAND-Kriterien entspricht, gehalten ist, nunmehr nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden, ob das Angebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND ist oder nicht. Denn hierdurch würde der Verletzungsprozess gerade wieder mit der Bestimmung belastet, welche Lizenzhöhe exakt und sonstigen Vertragsbedingungen ganz genau diesen Kriterien entsprechen, was aus Sicht der Kammer nicht das Anliegen des Gerichtshofs war. Kartellrechtswidrig und ersichtlich nicht FRAND ist ein Angebot erst dann, wenn es sich unter Berücksichtigung der konkreten Verhandlungssituation und insbesondere der Marktgegebenheit als Ausdruck von Ausbeutungsmissbrauch darstellt. Dies bedeutet freilich nicht, das der Patentinhaber sich mit der bloßen Behauptung begnügen dürfte, seine Forderung sei fair, vernünftig und nicht diskriminierend.

Der Patentinhaber hat vielmehr dabei die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühr so anzugeben, dass hierin deutlich wird, aus welchen dazulegenden Gründen er von einer Erfüllung der FRAND-Kriterien ausgeht. Nach Auffassung der Kammer wird der SEP-Inhaber den angeblichen Verletzer deshalb in die Lage versetzen müssen, anhand objektiver Kriterien nachzuvollziehen, warum der SEP-Inhaber zu der Überzeugung gelangt, dass das von ihm unterbreitete Angebot FRAND-Kriterien entspricht. Hierfür ist nicht ausreichend, dass der SEP-Inhaber bei einem Stücklizenzvertrag schlicht den pro Einheit zu zahlenden Betrag angibt, ohne zu erläutern, weshalb dieser Betrag nach seiner Ansicht FRAND-Bedingungen entspricht. Insoweit wird er den Betrag gegenüber dem vermeintlichen Verletzer in geeigneter Weise transparent zu machen haben, etwa durch Vortrag zu einem in der Vertragspraxis gelebten und von Dritten akzeptierten Standardlizenzprogramm oder unter Heranziehung anderer Bezugsgrößen, aus denen die geforderte Lizenzgebühr abgeleitet wird, wie etwa aus einer Poollizenzgebühr, die in der Praxis für einen Patentpool von Dritten gezahlt wird, der auch für den fraglichen Standard relevante Patente umfasst.

Der Verletzer muss auf dieses Angebot reagieren, selbst wenn es seiner Auffassung – wie regelmäßig – nicht den FRAND-Kriterien entspricht (ebenso im Ergebnis LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Seite 51 bei (bb) und LG Düsseldorf, Urteil vom 3. November 2015 - 4a O 144/14). Eine Ausnahme hiervon ist nach der Auffassung der Kammer allein in solchen Fällen zu machen, in denen sich das Angebot des SEP-Inhabers bereits bei summarischer Prüfung evident als nicht FRAND und mithin als Missbrauch einer beherrschenden Stellung des SEP-Inhabers darstellt. Dieses Gegenangebot ist alsbald zu unterbreiten, da der Gerichtshof dem angeblichen Patentverletzer keine Verzögerungstaktik zugestehen will. Mithin muss vom angeblichen Verletzter auf das konkrete schriftliche Angebot des SEP-Inhabers so schnell reagiert werden, wie dies nach den Umständen des Einzelfalls bei Anwendung der in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und des Grundsatzes von Treu und Glauben von ihm erwartet werden kann.

Schlägt der SEP-Inhaber dieses Angebot aus und hat der angebliche Verletzer das SEP bereits benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde, verlangt der Gerichtshof, dass er ab dem Zeitpunkt der Ablehnung des Gegenangebots eine angemessene Sicherheit etwa durch Beibringung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung leistet. Die Berechnung der Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergangenen

Benutzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen, für die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen können muss. Diese Sicherheit muss zudem den in dem betreffenden Bereich anerkannten Gepflogenheiten entsprechen.

2. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe ist die Klägerin vorliegend nicht aus kartellrechtlichen Gründen gehindert, die mit der Klage verfolgten Ansprüche insbesondere auf Unterlassung, Rückruf/Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung durchzusetzen, so dass letztlich offen bleiben kann, ob die Klagepatente der Klägerin eine marktbeherrschende Stellung vermitteln.

   a) Ob diese Maßstäbe der Kammer vor dem Hintergrund des Beschlusses des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 31. Mai 2016, Az.: 6 U 55/15, der meint, dass eine Evidenzkontrolle des Angebots des SEP-Inhabers einerseits nicht ausreichend sei, andererseits aber ausführt, dem SEP-Inhaber sei bei der Beurteilung, was FRAND sei, ein Entscheidungsspielraum zuzugestehen, und der lediglich eine summarische Prüfung im Rahmen eines Antrags auf einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung aus einem erstinstanzlichen Urteil betrifft, einer Überprüfung unterzogen werden müssen, kann vorliegend offen bleiben. Denn im konkreten Fall hat die Beklagte ihre Lizenzbereitschaft nicht rechtzeitig zum Ausdruck gebracht.

   b) Die Klägerin hat ihre Hinweispflicht nach den Maßgaben der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erfüllt. Bereits mit Schreiben vom 28.07.2015 hat die Klägerin der A SAS die betroffenen Patente und Mobilstationen bezeichnet. Sie hat ferner eine Liste vorgelegt, in der für jedes der Patente Abschnitte aus den Standards genannt werden, aus denen sich die Patentverletzung ihrer Ansicht nach ergibt. So wird in der Liste der Patente der einschlägige Patentanspruch genannt und auf das jeweilige Standarddokument verwiesen. Hieraus lassen sich die wesentlichen Informationen für die Patentverletzung gewinnen. Auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich um eine relativ junge Gesellschaft handelt, die die Mobiltelefone auch nicht selbst herstellt, war es der A SAS möglich, ggf. unter zumutbarer Inanspruchnahme von Hilfe von dritter Seite den Verletzungsvorwurf ausreichend nachzuvollziehen.

   Bei alledem war zu berücksichtigen, dass es grundsätzlich Sache des Patentbenutzers ist, sich über die Schutzrechtslage in seinem Geschäftsfeld zu informieren. Gerade in Anbetracht der großen Zahl der SEP, die eine Übersicht erschweren und aufgrund der nicht sicher ist, dass der Patentbenutzer zwangsläufig

weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessentiellen Patents benutzt (EuGH, a.a.O., Rn. 62), hat der Gerichtshof die Hinweispflicht aufgestellt, die den Patentbenutzer in die Lage verletzen soll, die Patentbenutzung zu erkennen. Die Verweise auf die wesentlichen Standardstellen genügen hierfür vollauf. Auf ihrer Grundlage kann der Patentbenutzer prüfen, ob der Vorwurf der Patentverletzung vertretbar ist oder nicht, und dementsprechend entscheiden, ob er in Lizenzverhandlungen eintreten möchte.

Soweit in Lizenzverhandlungen die Überlassung von Claim-Charts üblich ist, führt diese Gepflogenheit jedenfalls nicht dazu, dass solche Claim Charts bereits zwingend im Rahmen des Verletzungshinweises zu überlassen wären, bevor der Patentbenutzer überhaupt seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zur FRAND-Bedingungen abzuschließen.

c) Die A SAS hätte demnach entsprechend den Grundsätzen der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auf den Verletzungshinweis reagieren müssen, indem sie ihre Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-Bedingungen zum Ausdruck bringt. Diese Reaktion muss innerhalb einer angemessenen Zeitspanne erfolgen, da nach der Entscheidung des Gerichtshofs Verzögerungstaktiken des Patentbenutzers ebenso wie ein Überfall durch den Patentinhaber mit einer Unterlassungsklage zu unterbinden sind. Wie lange die Zeitspanne zu bemessen ist, innerhalb derer der Patentinhaber nach Treu und Glauben mit einer Reaktion rechnen darf und der Patentbenutzer deshalb seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringen muss, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere der Komplexität des erhobenen Verletzungsvorwurfs und dem Umfang der gelieferten Informationen. Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass sich der Patentbenutzer dadurch, dass er seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringt, mit Blick auf den Verletzungsvorwurf und den Rechtsbestand in keiner Weise binden muss. Es ist ihm nämlich trotz erklärter Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags nach FRAND-Bedingungen unbenommen und stellt die zum Ausdruck gebrachte Lizenzbereitschaft nicht in Frage, wenn er während den Verhandlungen über die Erteilung von Lizenzen die Rechtsbeständigkeit der nämlichen Patente und/oder deren essentiellen Charakter für den einschlägigen Standard, und/oder ihre tatsächliche Benutzung anficht oder sich die Möglichkeit vorbehält, dies später zu tun (EuGH, a.a.O., Rn. 69). Hieraus folgt, dass sich der Patentbenutzer damit, seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu

bringen, nicht Zeit lassen darf, bis er vollends von der Benutzung und dem Rechtsbestand des fraglichen Patents überzeugt ist. Ein solcher Bedeutungsinhalt kommt der Lizenzbereitschaftserklärung im Regime des Gerichtshofs gerade nicht zu. Vielmehr muss der vermeintliche Patentbenutzer nach dem Hinweis des Patentinhabers bereits in einem frühen Stadium Farbe bekennen und zum Ausdruck bringen, ob er grundsätzlich bereit ist, Lizenz zu nehmen, so dass es für den Patentinhaber Sinn macht, ihm ein Angebot zu unterbreiten und die Art und Weise der Berechnung des Lizenzsatzes zu erläutern, um in konkrete Verhandlungen einzutreten, oder er dies rundweg ablehnt. Um eine so verstandene Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen, bedarf es keiner Zeiträume, wie sie eventuell für eine eingehende Prüfung des Verletzungsvorwurfs und des Rechtsbestands im Einzelfall erforderlich sein mögen. Es reicht vielmehr ein Zeitraum, der es erlaubt, sich einen ersten Überblick über die Qualität des Verletzungsvorwurfs zu machen, insbesondere um zu beurteilen, ob der Vorwurf von vornherein abwegig ist oder ob er eine Berechtigung haben könnte, weil er nicht unvertretbar erscheint, zumal der Patentbenutzer sich nach dem Urteil des Gerichtshofs vorbehalten kann, die Patentverletzung und den Rechtsbestand einer gerichtlichen Prüfung zu unterziehen, was jedenfalls mit Blick auf den Verletzungstatbestand nur dann einen Sinn macht, wenn der Patentbenutzer von einer Patentverletzung nicht überzeugt ist. Ist ein Portfolio Gegenstand des Verletzungsvorwurfs und strebt der Patentbenutzer im Einklang mit den üblichen geschäftlichen Gepflogenheiten eine Lizenzvergabe am gesamten Portfolio an, ist es erst Recht nicht erforderlich, einen Zeitraum anzusetzen, der es ermöglichen würde, jedes einzelne Portfolio-Patent mit Blick auf seine Benutzung und seinen Rechtsbestand im Detail zu prüfen. Auch insoweit genügt ein Zeitraum, der dafür ausreicht, um sich einen Überblick über das Portfolio zu verschaffen, etwa indem ihrer Bezeichnung nach besonders relevante Patente vorrangig in den Blick genommen werden. Bei Zugrundelegen dieser Maßstäbe war die Lizenzbereitschaftserklärung der A SAS zu dem Zeitpunkt, als sie die Klägerin erreichte, verspätet.

aa) Die A SAS hatte ihre Lizenzbereitschaft nicht bereits im Rahmen der ersten Phase der Kontakte zwischen den Parteien bis zum Schreiben vom 28.07.2015 zum Ausdruck gebracht. Es kann daher offen bleiben, ob eine vor Erhalt eines den Anforderungen in Sachen Huawei ./. ZTE genügenden Hinweises, hier in Gestalt des Schreibens vom 28.07.2015, zum Ausdruck gebrachte

Lizenzbereitschaft fortbesteht oder nach Erhalt des Hinweises nochmals wiederholt werden müsste.

Die A SAS hat auf die Terminsvorschläge der Klägerin nämlich entweder mit Absagen oder überhaupt nicht reagiert. Hierin kann kein Ausdruck einer Lizenzbereitschaft gesehen werden, da es auch Teil einer Verzögerungstaktik sein kann, Terminsvorschläge schlicht abzusagen oder hierauf nicht zu reagieren. Eine Lizenzbereitschaft kommt auch nicht dadurch zum Ausdruck, dass der E-Mail-Wechsel unter dem Betreff *„patent license discussion with A"* stattfand. Diesen Betreff hatte nämlich die Klägerin in der Ausgangs-E-Mail vom 19.11.2014 gewählt, mit der sie an eine ausstehende Reaktion auf ihr erstes Schreiben vom 13.10.2014 und den dortigen Vorschlag für ein Treffen vor Ende November 2014 erinnert hatte. Der Betreff wird bei einer Antwort automatisch übernommen. Aus dem Umstand, dass die A SAS die Antwortfunktion genutzt und den Standard-Antwort-Betreff übernommen hat, ohne ihn abzuändern, kann nicht abgeleitet werden, dass sie hierdurch ihre Lizenzbereitschaft zum Ausdruck gebracht hätte.

bb) Soweit die A SAS nach Erhalt des Schreibens vom 28.07.2015 mit dem Lizenzangebot und den technischen Hinweisen zum Verletzungsvorwurf mit Schreiben mit Datum vom 16.10.2015 reagiert und erklärt hat, relevante IP-Rechte Dritter vollumfänglich zu respektieren und stets bereit zu sein, nach Treu und Glauben Bedingungen einer Lizenz für werthaltige Patente zu verhandeln, war diese Reaktion verspätet. Wie von der Klägerin behauptet und von der Beklagten nicht bestritten, wurde das Schreiben erst am 20.10.2015 auf den Postweg zur Klägerin gegeben. Demnach kann die Klägerin das Schreiben frühestens am 21.10.2015 erhalten haben. Zwischen dem Schreiben und dem Verletzungshinweis vom 28.07.2015 lagen rund zweieinhalb Monate. Selbst unter Berücksichtigung des Umstands, dass der August Ferienmonat in Frankreich ist und dass die A SAS – zu Argumentationszwecken unterstellt – über keine eigene technische Erfahrung verfügt, wäre zu erwarten gewesen, dass sie ihre Bereitschaft, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, deutlich vor dem 16.10.2015 zum Ausdruck bringt, da bis dahin ausreichend Zeit bestand, um den Sachverhalt in dem oben dargelegten Umfang zu prüfen.

Auch der Umstand, dass die Klägerin der A SAS unter dem 25.09.2015 ergänzend Claim-Charts überlassen hat, entbindet diese nicht davon, eine Reaktion zu zeigen. Die Überlassung zusätzlicher Informationen, die über das

hinausgehen, was für einen Verletzungshinweis im Sinne des Huawei ./. ZTE-Urteils des Europäischen Gerichtshofs erforderlich ist, berührt nämlich den Umstand nicht, dass der Patentbenutzer bereits aufgrund des Hinweises in der Lage war, sich ein Bild zu machen, das ausreicht, um eine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen oder zu verneinen. Durch die Überlassung solcher zusätzlicher Informationen kann der Patentbenutzer nicht schlechter stehen, als wenn er sie nicht überlassen hätte. Ob im Einzelfall etwas anderes gilt, wenn sich auf der Grundlage der zusätzlichen Informationen ein völlig vom bisherigen Verletzungsvorwurf abweichendes Bild ergibt, so dass der Patentinhaber nach Treu und Glauben davon ausgehen muss, dass der Patentbenutzer von neuem in die Prüfung einsteigen muss, bedarf vorliegend keiner Entscheidung, da die Beklagte einen solchen Sachverhalt nicht behauptet und er auch sonst nicht ersichtlich ist. Im Übrigen hätte die A SAS der Klägerin auch mitteilen können, dass sie noch über mehr Zeit für die Prüfung der Unterlagen benötigt. Da sie jedoch weder auf das Schreiben vom 28.07.2015 noch auf die E-Mail vom 25.09.2015 eine Reaktion gezeigt hat, musste sich der Klägerin der Eindruck aufdrängen, dass die A SAS kein Interesse an Lizenzverhandlungen hat. Eine Indikation von Seiten der A SAS vor dem Schreiben vom 16.10.2015, auch nur einen Gesprächsfaden aufnehmen zu wollen, ist weder vorgetragen, noch ersichtlich. Angesichts dieser Umstände kann der Klägerin nicht vorgeworfen werden, sie würde durch die Erhebung der Klage eine marktbeherrschende Stellung missbrauchen und kartellrechtswidrigen Druck aufbauen.

Vor diesem Hintergrund kommt es nicht darauf an, ob das Schreiben, das unstreitig erst am 20.10.2015 auf den Postweg zur Klägerin gegeben wurde, erst unter dem Eindruck des Erhalts einer französischen Klageschrift der Klägerin zu anderen Patenten am 19.10.2015 entstanden und zurückdatiert sein könnte, wie die Klägerin in den Raum gestellt hat.

cc) Ob auch eine verspätete Lizenzbereitschaftserklärung die Einreichung einer Unterlassungsklage hindert, bedarf vorliegend keiner allgemeinen Entscheidung. Jedenfalls dann, wenn der Patentinhaber im Zeitpunkt des Zugangs der verspäteten Lizenzbereitschaftserklärung bereits berechtigterweise Klage eingereicht hat, weil er die Anforderungen aus der Entscheidung Huawei ./.ZTE, die für die Phase bis zur Lizenzbereitschaftserklärung des Patentbenutzers gelten, erfüllt hat, ist er nicht gehalten, die eingereichte Klage anzuhalten. Ein

solches Erfordernis lässt sich dem Urteil des Gerichtshofs in Sachen Huawei ./. ZTE nicht entnehmen. Die den Patentbenutzer treffenden Obliegenheiten würden entwertet, wenn er diese nach Klageeinreichung beliebig nachholen und damit der eingereichten Klage die Grundlage entziehen könnte. In diesem Fall würde es nämlich für den Patentbenutzer ohne signifikante Folgen bleiben, wenn er sich vor Klageeinreichung nicht auf Lizenzverhandlungen einlässt, und jeder Anreiz für außergerichtliche Verhandlungen ginge verloren. Zwar mag der Patentbenutzer die Kosten des Rechtsstreit tragen, wenn der Patentverletzer den Rechtsstreit daraufhin für erledigt erklärt. Hierbei handelt es sich indes um keinen so schwerwiegenden Nachteil, als dass er für den Patentbenutzer einen hinreichenden Anreiz begründen könnte, es nicht auf eine Klage ankommen zu lassen, sondern Lizenzverhandlungen aufzunehmen. Zum einen fallen diese Kosten nämlich nicht ins Gewicht, zumal dann nicht, wenn man sie als Preis dafür auffasst, auf die Chance, dass der Patentinhaber doch von einer gerichtlichen Durchsetzung absieht, zu spekulieren. Zum anderen ist es auch nicht gesichert, dass in jedem Mitgliedstaat der EU eine entsprechende Kostenregelung existiert. Darüber hinaus ist auch kein Grund ersichtlich, die Klageeinreichung durch den Patentinhaber als missbräuchlich zu werten, wenn der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft nicht wie geschuldet zum Ausdruck gebracht hat und der Patentinhaber daher den Eindruck gewinnen musste, dass der Patentbenutzer nicht lizenzwillig ist. Zeigt sich der Patentbenutzer nicht rechtzeitig lizenzwillig und kommt es daher zu Verzögerungen, gibt es keinen Grund, den Patentinhaber weiter von der Durchsetzung seines zeitlich ohnehin nur beschränkten Ausschließlichkeitsrechts auszuschließen. Im Einklang hiermit steht, dass der Europäische Gerichtshof (a.a.O., Rn. 65) betont, dass Verzögerungstaktiken auf Seiten des Patentbenutzers zu vermeiden seien. Schließlich ergibt sich auch daraus, dass sowohl der Hinweis des Patentinhabers auf die Patentverletzung als auch das konkrete Lizenzvertragsangebot und die Erläuterung der Art und Weise der Lizenzberechnung vor Klageerhebung erfolgen müssen, dass auch der Patentbenutzter seine Lizenzbereitschaft zwingend vor Klageerhebung zum Ausdruck bringen muss, da hierdurch überhaupt erst die vor Klageerhebung durch den Patentinhaber zu erfüllende Obliegenheit ausgelöst wird, ein konkretes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung zu erläutern. Eine Nachholung der Lizenzbereitschaftserklärung ist daher nicht möglich. Die Kammer sieht sich in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass der Gerichtshof

insoweit durch Berichtigungsbeschluss klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Klageerhebung" sowohl auf die Erläuterung zur Patentverletzung als auch auf Vorlage des Lizenzangebots und die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen, und damit das Erfordernis vor Klageerhebung nochmals betont hat, so dass auch der Zwischenschritt, nämlich dass der Patentbenutzer seine Lizenzbereitschaft zum Ausdruck bringt, vor Klageerhebung zu erfolgen hat.

Dabei versteht die Kammer den Begriff der Klageerhebung im Sinne der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Sinne von Klageeinreichung und nicht im Sinne der Klageerhebung nach ZPO, die erst mit Zustellung erfolgt. Es ist nämlich nichts dafür ersichtlich, dass der Gerichtshof zwischen der Einreichung der Klage und einer gerichtlichen Zustellung differenzieren wollte und erst die Zustellung kartellrechtlich bedenklich wäre. Da andere Mitgliedstaaten die deutsche Unterscheidung zwischen Einreichung und Zustellung der Klage nicht kennen, kann überdies nicht davon ausgegangen werden, dass der Gerichtshof den Begriff der Klageerhebung im Sinne der deutschen ZPO verwendet hätte. Auf die Besonderheiten der jeweiligen nationalen Prozessrechte kommt es auch nicht an, da das kartellrechtlich relevante Verhalten die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ist, unabhängig davon, durch wen und wann die Klage nach den nationalen Verfahrensordnungen der einzelnen Mitgliedsstaaten zugestellt wird. Vor diesem Hintergrund ist es daher ohne Belang, dass die vorliegende Klage der Beklagten erst zugestellt wurde, nachdem die Klägerin das Schreiben vom 16.10.2015 erhalten hatte.

dd) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist ihr das Verhalten der A SAS auch zuzurechnen. Es entspricht den üblichen Gepflogenheiten, dass in Konstellationen wie der vorliegenden, in der Portfolio-Patente in mehreren Schutzstaaten gelten und der Patentbenutzer eine Unternehmensgruppe ist, der in mehreren dieser Staaten ebenfalls patentbenutzende Produkte vertreibt, der Patentinhaber nicht an jede einzelne nationale Vertriebsgesellschaft der Unternehmensgruppe herantritt und für deren Vertriebsgebiet individuelle Lizenzverträge verhandelt, sondern dass die Lizenzverhandlungen mit der führenden Gesellschaft über eine weltweite Portfolio-Lizenz geführt werden, die dann auch den einzelnen gruppenangehörigen Gesellschaften zugutekommt. Soweit die Beklagte vorliegend geltend macht, sie habe bis zum 29.08.2016

nicht dem Konzernverbund der A SAS bzw. der D angehört, da sie bis dahin einen Minderheitsgesellschafter mit 49 % Anteilen gehabt habe und Lizenzverträge ausweislich ihres Gesellschaftsvertrags zu den Beschlusspunkten gehörten, für die eine einstimmige Beschlussfassung durch die Gesellschafter vorgesehen sei, rechtfertigt dies keine andere Bewertung. Die Beklagte behauptet nämlich nicht, dass zwischen ihren Gesellschaftern oder zwischen ihr und der A SAS ein Dissens über die Frage des Abschlusses eines Lizenzvertrags bestanden habe, so dass sich in der Unternehmensgruppe kein einheitlicher Wille hätte bilden können.

Unerheblich ist auch, dass die Klägerin die A SAS und nicht die Mutter D angesprochen hat, denn ausweislich der von der Klägerin dargelegten Umstände handelt es sich bei der A SAS um diejenige Gesellschaft innerhalb der A-Gruppe, die als Ansprechpartner in Lizenzsachen fungiert. Dem ist die Beklagte nicht hinreichend entgegengetreten, sondern hat lediglich vorgebracht, dass sie selbst nicht konzernverbunden sei.

ee) Ohne Bedeutung für die Frage, ob die Beklagte bzw. A SAS ihre Lizenzbereitschaft rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hat, ist der Umstand, dass die Beklagte bzw. A SAS nach Klageerhebung ein Lizenzangebot vorgelegt, über die angeblichen Umsätze Auskunft erteilt und einen namhaften Betrag hinterlegt haben. Wie die Kammer bereits in anderem Zusammenhang entschieden hat, kann zwar das Verhalten der Beklagten nach Klageerhebung u.U. ein Indiz für ihre grundsätzliche vorgerichtliche Bereitschaft, in Lizenzvertragsverhandlungen mit der Klägerin einzutreten, gewertet werden. Dies setzt allerdings voraus, dass bereits vor Klageerhebung ein Verhalten stattgefunden hat, das eine solche Lizenzbereitschaft grundsätzlich zum Ausdruck bringt. Nur in einem solchen Fall kann die Bewertung dieses Verhaltens als Lizenzbereitschaft weiter durch das Verhalten nach Klageerhebung bestätigt werden. Ein Verhalten nach Klageerhebung kann indes das Erfordernis, dass die Lizenzbereitschaft fristgemäß zum Ausdruck gebracht worden sein muss, nicht ersetzen.

d) Da die A SAS ihre Lizenzbereitschaft nicht rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hat und die Klägerin daher berechtigterweise Klage erheben und ihre Klage auch weiter betreiben durfte, kommt es nicht darauf an, ob das Lizenzangebot der Klägerin FRAND-Bedingungen genügt und sie die Art und Weise der Berechnung der

Lizenzgebühr vor Klageerhebung ausreichend erläutert hat, denn hierzu war sie nicht verpflichtet, da diese Obliegenheiten sie erst dann getroffen hätten, wenn die A SAS ihre Lizenzbereitschaft rechtzeitig zum Ausdruck gebracht hätte. Ist die Klage zulässigerweise erhoben, ist der Patentinhaber auch nicht verpflichtet, die ihn für die Phase vor Klageerhebung treffenden Obliegenheiten nachzuholen, wenn der Patentbenutzer nach Klageerhebung nunmehr die ihm obliegenden Verhaltensweisen nachträglich erfüllt. Denn auch insoweit gilt, dass ein Verstoß des Patentbenutzers gegen die ihn treffenden Verhaltensregeln andernfalls sanktionslos bliebe und daher kein Anreiz zu ihrer vorprozessualen Einhaltung bestünde, wenn der Patentbenutzer sie noch während des Gerichtsverfahrens nachholen und damit den Patentinhaber dazu zwingen könnte, einen Schritt zurück in die Phase der nach dem Konzept des Europäischen Gerichtshofs vor Klageerhebung angesiedelten Verhandlungen zu gehen, und ihn damit für geraume Zeit der Durchsetzung seiner Ausschließlichkeitsrechte berauben könnte.

e) Soweit die Klage auf Erteilung von Auskünften und Rechnungslegung sowie die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung gerichtet ist, stehen der Geltendmachung dieser Ansprüche kartellrechtliche Gesichtspunkte von vornherein nicht entgegen (vgl. Huawei Technologies/ZTE (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2015 – C-170/13, GRUR 2015, 764 Rn. 72 ff. = ECLI:EU:C:2015:477 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15. Dezember 2015, ECLI:EU:C:2015:817).

IV. Schließlich ist auch keine Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits mit Blick auf die von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage geboten.

1. Eine solche Aussetzung suspendiert die Durchsetzung der Rechte aus dem Klagepatent. Da der Verletzungsrichter im Grundsatz an den Erteilungsakt gebunden ist, kommt eine Suspendierung der aus erteilten Ausschließlichkeitsrecht folgenden Befugnisse nur unter besonderen Umständen in Betracht. Die bloße Möglichkeit, dass das Klagepatent vernichtet wird, ist insoweit nicht ausreichend. Vielmehr ist erforderlich, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit (BGH, Urteil vom 16. September 2014 - X ZR 61/13, GRUR 2014, 1237 - Kurznachrichten) für die Vernichtung des Klagepatents besteht.

2. Die Nichtigkeitsklage vermag diesen Maßstäben nicht zu genügen.

a) Unabhängig von dem zwischen den Parteien bestehenden Dissens über das Veröffentlichungsdatum der Entgegenhaltung „Optimal Antipodal Signaling" (NK1)und ihrer Zugänglichkeit kann sich die nicht fachmännisch besetzte Kammer keine hinreichende Überzeugung davon bilden, dass die Lehre des Klagepatents hierdurch bzw. durch das Dokument in der Fassung der Revision 1 (NK1a)neuheitsschädlich getroffen wird.

Die Schrift zeigt aus Sicht der Kammer jedenfalls nicht hinreichend deutlich für einen Nicht-Fachmann, dass die dort verwendeten Parameter p_{fack} und p_{fnack}, die nach der Darlegung der Beklagten „seitens der Basisstation ein bestimmtes Qualitätserfordernis an die tolerierten Wahrscheinlichkeiten falsch erkannter ACK- bzw. NACK-Nachrichten an das Endgerät in Form erforderlicher Wahrscheinlichkeiten" stellen sollen, - bei Zugrundelegung derselben Maßstäbe an die Auslegung des Merkmals f2 wie bei der Beurteilung der Verletzung – als Angabe eines – sei es auch nur mittelbar bestimmbaren – Leistungspegels verstanden werden können. Denn selbst wenn die in der Schrift erwähnten Verstärkungsparameter k und l für den Fall, dass die überwachten Werte für p_{fack} und p_{fnack} nicht dem durch die Basisstation in Form von p_{fack_req} und p_{fnack_req} vorgegebenen Qualitätserfordernis entsprechen, dazu führen sollten, dass die Verstärkungsparameter k und l angepasst werden und hierdurch wiederum die Sendeleistung der ACK- und NACK-Signale angepasst wird, so kann seitens der nicht fachmännisch besetzten Kammer insoweit nicht hinreichend sicher beurteilt werden, ob der Fachmann hierdurch als in der Schrift offenbarten Lehre unmittelbar und eindeutig offenbart entnimmt, dass die beschriebene Leistungsanpassung für jeden Signaltyp im Sinne des Merkmals f2 in Abhängigkeit einer Angabe des Leistungspegels seitens der Primärstation zu der Sekundärstation vorgenommen wird und mithin die nach dem Vortrag der Beklagten stattfindende Leistungsanpassung als Mittel zur sicheren Detektion der ACK-/NACK-Nachrichten durch die Primärstation eingesetzt wird. Zwar könnte somit die Ausführungen der Beklagten als zutreffend unterstellt in der Schrift faktisch eine Leistungsanpassung stattfinden, diese sich aber lediglich als Vorgang gelegentlich der Anpassung der erwarteten Fehlerwahrscheinlichkeiten darstellen und vom Fachmann nicht hinreichend eindeutig als Mittel zur Lösung der Fehldetektion des ACK-/NACK-Signals durch Vorgabe eines Leistungspegels zu

erkennen sein. Dies zu beurteilen, muss vorliegend dem Rechtsbestandsverfahren vorbehalten bleiben, ohne dass deshalb der Verletzungsstreit auszusetzen wäre.

b) Soweit die Beklagte weiter argumentiert, die klagepatentgemäße Lehre erweise sich durch die Schriften NK2 und NK5 als neuheitsschädlich getroffen, ist die nicht fachmännisch besetzte Kammer nicht in der Lage, eine ganz überwiegende Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der angesprochene Fachmann in diesen Schriften die klagepatentgemäße Lehre eindeutig und unmittelbar offenbart findet.

aa) Es erscheint der Kammer zweifelhaft, ob in dem Dokument NK2 überhaupt der Leistungspegel, bei dem das Signal gesendet wird, in Abhängigkeit seines Typs ausgewählt wird, da insoweit sowohl für ACK- als auch für NACK-Nachrichten der nämliche Übertragungsleistungspegel ausgewählt zu werden scheint. Damit erscheint die Offenbarung des Merkmals f1 fraglich.

bb) Mit Blick auf die Entgegenhaltung NK5 hat die Kammer wiederum Zweifel, dass der angesprochene Fachmann die zweite AP-Nachricht, die in der Figur 2 mit der Bezugsziffer 202B versehen ist, als eine NACK-Nachricht deutet, wie dies die Beklagte geltend macht. Denn das Netzwerk scheint bei dem gezeigten Übertragungsschema gerade nicht zu registrieren, dass es zuvor einen gescheiterten Übertragungsversuch der AP-Nachricht gegeben hat, wobei diese erste AP-Nachricht mit einem niedrigeren Leistungslevel (vgl. Bezugsziffer 202A) gesendet wurde. Somit ist fraglich, ob der Fachmann der Übermittlung der AP 202B überhaupt eine Angabe über den Status des empfangenen Datenpakets entnimmt. Vielmehr scheint lediglich in der Phase des Aufbaus einer Übertragung ein Signal gegebenenfalls wiederholt mit erhöhter Leistung übertragen zu werden, bis die Übermittlung mit einer ACK-Nachricht bestätigt wurde, weshalb zweifelhaft ist, ob der Fachmann in der NK5 das Merkmal d offenbart findet.

VI. Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 92, 709 S. 1 und 2 ZPO.

Verkündet am 25.11.2016

_____

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle